

1501196-43.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. LICENÇA DE SAÚDE. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal disponha que "O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença", o preceito contido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

2ª Vara JUDICIAL

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780 - Centro - CEP: 07600-225 - Mairiporã - SP

Telefone: (11) 4419-5636 - E-mail: mairipora2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501196-43.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501196-43.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMILY CARDOSO FRANCO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LARISSA BONI VALIERIS

Vistos.

EMILY CARSOSO FRANCO, já qualificada nos autos em epígrafe, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 03 de Maio de 2021, por volta das 14h, na rua Hakuji Yokomiro, 30, Jardim Nipon, nesta cidade e Comarca de Mairiporã, teria trazido consigo 25,73g de cocaína em forma sólida pertrificada ("crack" - massa líquida de 2,53g), acondicionada em 29 microtubos de plástico ("eppendorf"), e 7,34g de cocaína em forma sólida particulada (massa líquida de 2,57g), acondicionada em 03 invólucros de plástico (papelote), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para comercialização e entrega a terceiro, (auto de exibição e apreensão - fls.8, laudo de constatação de fls.10/14). Conforme a denúncia (fls.68/70) e, segundo o apurado, a ré, em tese, resolveu realizar comércio ilícito em local conhecido como "ponto" de venda de drogas e, para isso, trazia consigo as drogas acima mencionadas, no interior de um saco. Na ocasião, Policiais Cíveis em diligência pelo local dos fatos e, teoricamente, visualizaram a ré na posse de um saco, no que decidiram abordá-la. Na sequência, os policiais realizaram a abordagem e, durante busca pessoal, teriam localizado no interior do saco da ré 29 pedras de "crack" (produto derivado da cocaína) e a quantia de R\$48,00. Assevera, a denúncia, que EMILY admitiu que estava ali praticando o tráfico, foi flagrada com substâncias ilícitas em local conhecido como "ponto" de venda de drogas, especialmente divididas de forma a permitir a imediata comercialização, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de drogas. A ré foi presa em flagrante (fls.01) e

conduzida até o distrito policial, ocasião que teria sido revistada por policial do sexo feminino, sendo encontrados, na calcinha da ré, mais 03 invólucros com cocaína. Em solo policial, a ré confessou o crime (fls.04).

Termo de Audiência de Custódia às fls.36/40, oportunidade em que foi concedida liberdade provisória impondo-lhe medidas cautelares, com base no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal. Alvarás fls.41/22.

Regularmente notificada, a ré, por intermédio de advogado constituído, apresentou defesa prévia às fls.79/80, pugnando pelo acordo de não persecução penal, e reservando-se o direito de promover sua defesa durante a instrução criminal.

Manifestação do Ministério Público às fls.84/87 em que pede indeferimento da aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, bem como o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos.

Decisão às fls.101/102 em que recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento.

Requerimento de renúncia do patrocínio outorgado pela procuração, visto que a ré não se encontra mais no endereço antes declinado (fls.123).

Em audiência de instrução e julgamento (fls.124/125), preliminarmente, com fulcro no artigo 265, do CPP foi aplicada multa de 01 (um) salário mínimo ao defensor constituído, diante de sua ausência neste ato e nomeada ad hoc outra defensora; em seguida, foi decretada revelia da ré, com fulcro no artigo 367, do Código de Processo Penal, considerando que não foi localizada, embora tivesse a obrigação de comunicar qualquer mudança de endereço ao Juízo quando lhe foi concedida liberdade provisória; finalmente, foram ouvidas as testemunhas.

Em alegações finais (fls.130/136), o d. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, para condenar o réu nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, opinou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante a quantidade de drogas apreendidas; nas fases seguintes não considerou nenhuma possível causa de aumento ou diminuição da pena.

No que tange ao regime, requereu o inicial fechado.

A d. defesa, por sua vez, em alegações finais (fls.151/154) requereu nulidade do procedimento anotando que não observa manifesto direito da acusada que reuniu todos os elementos autorizadores para a Não Persecução Penal. Ainda, por entender indubitável que o processo não prosseguirá, optou por sustentar o mérito em oportuna ocasião. A cerca da imposição de multa, pugnou que seja reconsiderada.

Certidão de Antecedentes Criminais às fls.138/140 e Folha de Antecedentes às fls.119/121.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, destaco se encontrar presente exceção à identidade física do juiz, tendo em vista que a DRA DANIELA AOKI DE ANDRADE MARIA se encontra em licença saúde. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. LICENÇA DE SAÚDE. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal disponha que "O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença", o preceito contido no referido dispositivo legal não pode ser aplicado de maneira absoluta, visto que a prestação jurisdicional dos togados investidos na competência para a apreciação e o julgamento de causas criminais passaria a ser, necessariamente, ininterrupta, impedindo-os de se afastar temporariamente de suas funções, seja por motivo de férias, de licença médica, de convocações, seja, até mesmo, de progressão funcional, o que é inerente à carreira. 2. Em razão da ausência de outras normas que regulamentam o disposto no referido artigo, esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a mitigação do aludido princípio nos casos de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou de qualquer outro motivo que impeça o juiz que houver presidido a instrução de sentenciar o feito. Aplica-se, por analogia (permitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal), o art. 132 do Código de Processo Civil. 3. O rol constante no art. 132 do CPC não é taxativo - haja vista a expressão "afastado por qualquer motivo", contida no caput -, razão pela qual a substituição é admitida também na hipótese de licença de saúde, tal

como ocorreu no caso. 4. Para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas. 5. O Tribunal de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 6. Agravo regimental não provido. (Superior Tribunal de Justiça. Sexta Turma. AgRg no Agravo em Recurso Especial 1579227/MG (2019/0270624-1). Relator Min. Rogério Schietti Cruz, 28/04/2020).

Já superado o momento para oferecimento do acordo de não persecução penal, não possuindo razão a defesa nos argumentos no sentido de que a ação não deve prosseguir.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente, ainda, quaisquer causas de nulidade que tenham ensejado prejuízo ao réu, passo ao exame do mérito.

Nesse passo, de pronto, anoto que a materialidade delitativa restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.01), Boletim de Ocorrência (fls.05/07), Auto de Exibição e Apreensão (fls.08), Laudo de Constatação de Entorpecente (cocaína - massa líquida: 2,83g; cocaína - massa líquida: 2,57g - fls.10/14), Termo de Depoimento (fls.02/03), Termo de Interrogatório em Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls.04), Auto de Qualificação (fls.15), Nota de Culpa (fls.17), Laudo de Lesão Corporal Cautelar (fls.34/35), Relatório Final (fls.62/64), Depósito Judicial (fls.55), bem como pelas provas orais colhidas. Logo, é certo que restou devidamente comprovado o objeto material “droga”, indicado no tipo penal do caso vertente, que prevê crime não transeunte, sendo regularmente apreciados os seus vestígios em prova tarifada pelo legislador (artigo 158, do Código de Processo Penal c.c. artigo 50, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/06 - LD).

Sobreleva notar que tal substância encontra-se expressamente prevista na Portaria 344/98 e Resolução nº 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (artigo 1º, Sú., da LD).

De outra banda, verifico que a autoria restou delineada, ante a consonância dos elementos colhidos na fase inquisitorial com aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A par disso, a testemunha Sadraque de Oliveira Campos da Silva, Policial Civil, em juízo, narrou que, o local dos fatos é conhecido por ocorrer o comércio de drogas; em diligência de rotina, visualizou a ré com um saco na mão; abordaram a ré; verificaram que no saco havia algumas porções de drogas e dinheiro trocado; após conduzir a ré para a delegacia, foi revistada por policial do sexo feminino, ocasião que foram encontradas outras três porções de cocaína nas partes íntimas da ré; indagada, EMILY confessou que estava vendendo as drogas para sustento do próprio vício.

Igualmente, a testemunha João Justino de Oliveira Sobrinho, Policial Civil, declarou que, o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes; em diligência pelo local, avistaram a ré na posse de uma sacola, com atitude suspeita; efetuaram a abordagem; dentro da sacola havia 29 eppendorfs de crack, e a quantia em dinheiro trocado de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais); conduziram a denunciada à delegacia e então foi revistada por policial feminina; foram encontradas outras “três sacolinhas com cocaína”(sic); a ré confessou a prática delitativa afirmando ser usuária de entorpecentes, que estava vendendo as drogas porque ao final do dia receberia outras drogas.

Ressalta-se que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se

harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 73518, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENTVOL-01846-02 PP-00293), o que, aliás, não se afere no caso em tela.

Como se vê, a prova é robusta o suficiente para embasar uma condenação, pois hialino que a ré praticou os núcleos "trazer consigo" e "vender", previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tipo misto alternativo, sendo certo que houve a apreensão de quantidade de droga suficiente para lesionar o bem jurídico tutelado, e já devidamente fracionada para venda, ainda mais porque não comprovou que exercia qualquer atividade remunerada à época dos fatos, donde se vê que sua conduta causou grande dano à saúde pública, além do fortalecimento de organizações paraestatais, violando o bem jurídico tutelado pela norma penal. De mais a mais, extrai-se o seu intuito comercial do próprio local em que concretizada a abordagem, qual seja, ponto de mercancia de drogas.

Incumbe salientar, igualmente, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de forma que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública, ou seja, "o crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT776/663). Logo, ainda nesta hipótese, restaria consumado o crime.

Por fim, nota-se que a acusada detinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

Na primeira fase da dosimetria da pena, entendo as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006 normais ao tipo. Destarte, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausente atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e possível a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da LD, dado que a ré é primária, de bons antecedentes e não restou cabalmente demonstrado que se dedicava às atividades criminosas, tampouco que integrava organização criminosa. Assim, diminuo a pena em 2/3, tornando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Assim, "Tratando-se de réu primário e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção do paciente em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe." (STJ, AgRg no HC 705.950/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

Ausentes elementos que denotam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

O regime inicial será o aberto, em exegese ao artigo 33, do Código Penal. Possível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, por ser medida mais adequada para absorção da terapêutica penal. Justifica-se a substituição por duas restritivas de direitos em razão do lapso temporal da pena substituída.

Cabível a substituição da pena, nos termos do artigo 44, do Código Penal, não há que se falar em suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal).

Ante o exposto, e por tudo o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré EMILY CARDOSO FRANCO à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor mínimo legal (artigo 49, "caput", e parágrafos, do Código Penal), por restar incursa nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, por ser medida mais adequada.

Custas e demais despesas pela ré, ressalvada hipótese de gratuidade processual (artigo 804, do Código Processual Penal).

Como a quantia apreendida e o bem apreendido estão intrinsecamente vinculados à prática delitiva - fruto da mercancia da droga -, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (artigo 72, da LD).

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Expeça-se guia de execução penal.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C., Mairiporã, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA